

제60회 변리사 2차 시험 상표법 총평

- 최지환 변리사 -

1. 문항 분석

(1) 문제 - 1 : 판례형

1번 문제는 최신 판례이자 중요 전원합의체 판례인 “DATA FACTORY 사건”의 사실관계를 기반으로 문제가 출제되어 많은 수험생분들이 어렵지 않게 답안을 구성해냈을 수 있을 것이라 생각합니다.

설문(1)은, 상표의 유사판단 및 요부관찰과 관련된 여러 법리들, 그리고 서비스간 유사판단 법리를 기재한 뒤 사안에 풍부하게 포섭하는 것이 핵심인 문제였습니다.

설문(2)는, 저희가 같이 잘 준비했던 “DATA FACTORY 사건”의 핵심 법리에 관한 논의를 풍부하게 적어준 뒤, 손해배상청구에서의 과실 추정 및 과실 추정 복명에 관한 법리를 제시하는 것이 핵심인 문제였습니다.

주목할 만한 점은, “DATA FACTORY 사건” 법리를 적용하는 문제가 작년에 나왔음에도 불구하고(물론 아주 부수적인 쟁점으로 출제되었지만) 올해 큰 배점의 문제로 다시 출제되었다는 것입니다. 제가 항상 GS 수업에서 강조하는 말 중에 『중요한 전원합의체 판결은 기출된 적이 있더라도 언제든지 다른 배점이나 형식으로 출제될 수 있다』는 말을 항상 기억하고 공부하실 필요가 있겠습니다.

(2) 문제 - 2 : 판례형

2번 문제는 2023년도에 선고된 최신 판례인 “masmi 사건”의 사실관계를 기반으로 하여 무효심판의 이해관계인 및 제34조 제1항 제13호에 관한 법리를 적은 배점으로 추가하여 물어보는 형태로 출제되었습니다.

설문(1) 및 (2)에서는 각 설문에서 물어보는 쟁점들에 관한 일반론을 적은 뒤 사안에 콤팩트하게 포섭하여, 이해관계인 및 제34조 제1항 제13호에 관한 기본 법리를 잘 알고 있다는 것을 보여주는 것이 핵심인 문제였습니다. 설문(1) 및 (2)는 배점이 매우 작기 때문에 ‘배점을 고려해 더 적을 수 있는 것도 자제하여 제한적으로 시간투자를 하는’ 소양을 충분히 발휘하는 것이 중요했을 것이라 생각합니다.

설문(3)은, 제34조 제1항 제20호에 관한 일반론(입법취지, 적용요건)과 함께 “masmi 사건”의 핵심 쟁점인 “외국회사가 국내에 유통할 목적으로 제3자를 통해 제품을 수출한 경우 20호 소정의 ‘국내 사용’으로 볼 수 있는지 여부”에 대해 풍부하게 논의하는 것이 핵심인 문제였습니다.

(3) 문제 - 3 : **단문 + 사례형**

3번 문제는 ‘사용에 의한 식별력’과 관련된 요건 및 판단기준을 주로 묻는 문제로서, 사실관계 또는 묻는 쟁점이 어렵지는 않았으나, ‘배점’ 및 ‘쟁점 안배’ 때문에 시험장에서 다소 당황스러움을 느꼈을 수 있을 것이라 생각합니다. 또한, 설문(1)과 설문(2)에서 ‘단문의 형식’으로 묻고 있어서 “사안 적용을 해야하는 문제인가?”에 관한 헛갈림이 드는 문제였을 것이라 생각하여, 생각보다 체감 난이도가 있었을 것이라 생각합니다.

설문(1)에서는 甲의 출원상표가 ‘본질적’으로 法33조1항3호에 해당한다는 점을 포섭한 뒤, 法33조2항에 해당함을 주장하기 위한 요건에 관하여 조문 내용을 분설하여 일반론을 풍부하게 기술하는 것이 핵심인 문제라고 생각합니다. 출제자의 의도가 명확하지는 않으나, ‘안전한 답안’의 관점에서는 각 요건에 관해 사안포섭도 간단히 기재해주는 것이 더 바람직하다고 생각합니다.

설문(2)는 법조문에 드러나는 요건 외에 ‘사용에 의한 식별력에 관한 판단기준’을 풍부하게 적어야 하는 문제로서, 아주 특수한 케이스에 적용되는 판례의 법리가 아닌 범위에서 다양한 판단기준을 적으면 더 좋을 것이라 생각하며, 가장 핵심적으로 적었어야 하는 법리는 “사용에 의한 식별력 취득의 판단방법(단박대출 사건에서 판시된 사항)” 및 “동일성 있는 상표의 장기간의 사용이 식별력 취득에 도움이 된다는 법리(K2 사건에서 판시된 사항)”입니다. 또한, 이하 설문에서 ‘사용에 의한 식별력 취득’에 따른 등록가능성을 더 이상 묻지 않기 때문에, 설문(2)에서 최종적으로 甲이 사용에 의한 식별력 취득을 인정받아 거절이유를 극복할 수 있을지 포섭하는 것도 필요했을 것이라 생각합니다.

설문(3)은 사용에 의한 식별력을 취득한 상표에 관하여 法90조1항2호를 적용할 것인지를 묻는 문제로서, 묻고있는 핵심 쟁점이 명확하여 답안 기술에 어려움이 없었을 것이라 생각합니다.

(4) 문제 - 4 : **판례 기반 사례형**

4번 문제는 권리소진이론에 관한 상표법상 리딩 케이스인 “후지필름 사건”의 사실관계를 기반으로 출제된 문제로서, 양 당사자의 주장사항을 묻는 형식으로 출제되었습니다.

설문(1)은 상표권 침해 성립요건을 검토한 뒤, ‘상표적 사용 미해당’ 및 ‘권리소진’에 관한 내용을 핵심 쟁점으로 잡아 관련 일반론 제시 및 ‘甲의 입장에서 사안포섭’을 적는 것이 핵심인 문제였습니다.

설문(2)는 乙의 입장에서 ‘상표적 사용’ 및 ‘권리소진’에 관한 甲의 항변에 어떤 근거로 반박할 수 있는지를 적는 문제로서, ‘乙의 입장에서 사안포섭’을 적는 것이 핵심인 문제였습니다. 실전GS B형 강의에서 설명 드렸듯이 2차 시험에서는 ‘객관적인 입장에서의 사안포섭’도 잘 해야 하지만, 양 당사자의 대립구조에서 ‘각 당사자의 입장에서의 사안포섭’을 요구하는 문제도 자주 출제되어오고 있으니 이 점을 유념하실 필요가 있습니다.

설문(3)은 ‘상표 바뀌치기’를 주제로 한 불의타 문제였습니다. 다만, 배점이 크지 않고, ‘기본이론’ 시간에 테마상표법 제6판 교재를 통해 설명이 충분히 되었기 때문에, 교재에 기술된 내용을 바탕으로 ‘전용권 침해’에 관한 법리를 통해 법리를 충분히 채울 수 있으셨을 것이라 생각합니다.

2. 전체 총평

이번 2차 상표법 과목은 전반적으로 난이도가 높지는 않았으나, (i) 다소 난해한 배점, (ii) 설문별 답안 쟁점 안배, (iii) 불의타 출제 등의 문제들로 인해 체감 난이도가 아주 쉽지는 않은 시험이었을 것이라 생각합니다.

다만, 상표의 유사판단, 상품의 유사판단, 사용에 의한 식별력, 주요 부등록사유 등 상표법상 중요한 쟁점들이 다수 출제되었고, “DATA FACTORY 사건”, “masmi 사건”, “후지필름 사건” 등 중요 판례 및 최신 판례들이 다수 출제되어, 중요 이론 및 중요 판례에 대한 학습의 중요성이 다시 한번 강조된 시험이었다고 생각합니다.

3. 맺음말

2차 시험을 치르신 수험생분들 모두들 너무 고생 많으셨습니다. 지금 당장은 계속 빠트린 논점들, 더 잘 쓸 수 있었던 논점들이 머릿속을 계속 맴돌겠지만, 어차피 여러분들 손을 떠난 시험일 뿐 아니라 어차피 모든 논점을 누락 없이 완벽하게 적고 나오는 수험생은 없기 때문에, 지금 당장 너무 상심하실 필요는 없다고 말씀 드리고 싶습니다.

짧게는 몇 개월, 길게는 몇 년 이상 준비하여 이번 시험을 치르셨을 텐데, 그 기간이 얼마이든 시험장에 끝까지 나가셔서 시험을 치르고 오셨다면, 그 자체만으로도 대단한 일을 하신 것이라고 말씀 드리고 싶습니다. 그러니 당분간은 시험에 관한 생각은 접어두시고 폭 쉬시고, 그 동안 챙기지 못했던 주변 가족, 친구들과 좋은 시간 많이 보내시길 바랍니다.

그럼 다시 한 번 다들 정말 고생 많으셨습니다. 감사합니다.